

1501525-45.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... agentes voltada à prática do crime de tráfico de entorpecentes, os acusados devem ser absolvidos em relação à imputação do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Destarte, de rigor a condenação dos réus apenas pelo crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Passo a dosar a pena a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501525-45.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501525-45.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO NUBIATO DA SILVA ROCHA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

V I S T O S.

JOÃO NUBIATO DA SILVA ROCHA e WELLINGTON ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no mês de outubro de 2021, nesta cidade, associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como no dia 31 de outubro de 2021, por volta das 10:00 horas, na Rua Minas Gerais, nº 159, Bairro Engenheiro Taveira, nesta cidade, tinham em depósito droga para consumo de terceiro sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram notificados e apresentaram defesas preliminares a fls. 197/201 (João) e 225/228 (Wellington). A denúncia foi recebida a fls. 238/241. No decorrer da instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os acusados (fls. 299/308).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia (oralmente a fls. 303/304). A Defesa do corréu Wellington requereu sua absolvição, sustentando, em síntese, que a prova é precária. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena no patamar mínimo, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (fls. 311/317). A Defesa do corréu João Lucas pediu sua absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico, alegando, em resumo, a atipicidade da conduta, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico de drogas e da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo, a imposição de regime inicial aberto para o cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 320/347).

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 25/26, laudos de constatação prévia de fls. 29/30 e exames químicos toxicológicos encartados a fls. 162/167, os quais resultaram positivos para maconha.

E a responsabilidade criminal dos acusados em relação ao delito do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 é indubitosa.

Com efeito, interrogado em Juízo, o réu WELLINGTON negou a prática do crime de tráfico. Disse que no dia dos fatos acordou cedo, assim como João, e foram tomar café na padaria. Avistaram a viatura e continuaram andando normalmente. Durante a abordagem, os policiais encontraram um cigarro de maconha com João e lhe indagaram se fumava maconha, o que confirmou. João falou para os policiais que possuía uma porção de maconha para uso dele na residência. Não disse nada nesse momento. Os policiais foram até sua residência, entraram e encontraram a porção mencionada por João. Também tinha droga para consumo em seu quarto, setenta e cinco "balinhas" de maconha. Comprou o entorpecente da forma como foi apreendido e o levava para fumar no serviço. Adquiriu a droga por R\$ 80,00 no sábado. Acredita que João não tinha conhecimento sobre esse entorpecente. Possuía moedas em um cofrinho no quarto, mas não sabe a quantia exata. Tinha pouco mais de R\$ 200,00 em dinheiro no momento da abordagem, quantia obtida com o trabalho montando tenda. Foi ouvido na Delegacia de Polícia, onde disse que a droga seria para seu consumo e que já vendeu para amigos. Não lembra de ter dito que resolveram fracionar a droga para venda. Todo o entorpecente apreendido seria destinado ao seu consumo. Moravam no Bairro São José anteriormente e se mudaram para aquela casa menos de dez dias antes dos fatos. Optaram pela mudança porque conhecem os moradores e gostam do bairro. Trabalhava com João em Araçatuba e Jales. Nunca foi processado. Conhece João desde criança e alugaram a casa menos de dez dias antes. Não moraram juntos anteriormente. Trabalhavam juntos e decidiram alugar a casa. Não sabe se a quantidade de droga encontrada no quarto de João era maior do que a que estava guardada no seu. Sabia que João tinha droga porque ele não fica sem fumar. Não franquearam o ingresso dos policiais na residência pelos policiais e eles não pediram autorização. Um homem chegou ao local com a mãe de João, mas não o conhece. Segundo os policiais, esse

homem teria autorizado a entrada.

O acusado JOÃO, interrogado em Juízo, admitiu já ter praticado tráfico, mas negou que a droga apreendida em seu quarto seria destinada à venda. Disse que na casa tinha droga, destinada principalmente ao consumo, mas que vendia quando alguém aparecia no local. Estava trabalhando e se mudou para Taveira fazia uma semana. Pegou a droga para usar, foram tomar café na padaria e foram abordados. Estava junto com Wellington. Os policiais encontraram um cigarro de maconha em seu bolso, além da quantia de R\$ 80,00 em dinheiro, fruto do trabalho montando tenda com Wellington. Nada de ilícito foi localizado com Wellington, apenas dinheiro também obtido com o trabalho. Após a localização do cigarro de maconha, os policiais lhe disseram que precisavam ir até sua casa. Foi indagado sobre se tinha droga na residência e respondeu que possuía um pedaço para fumar. Não autorizou o ingresso na casa e os policiais também não pediram para entrar. Seu padrasto estava em frente à residência quando chegaram, mas não sabe se ele autorizou a entrada no local. Os policiais encontraram maconha na residência. A porção de maconha que estava em seu quarto pesava cerca de quinze gramas e seria para consumo. Também tinha dinheiro do trabalho no quarto, cerca de R\$ 700,00. Os milicianos localizaram porções de maconha no quarto de Wellington, mas não sabe a quantidade. Não sabia que Wellington tinha droga no quarto. Vendia droga quando saíam para o serviço, mas não na casa. Cada porção de maconha era vendida por R\$ 5,00. Não sabe se Wellington também vendia entorpecente. Vendeu droga durante uma semana. Ainda não tinha recebido o dinheiro das vendas. Vendeu no máximo vinte porções, o que fazia no trabalho. Veio do Mato Grosso e morou com a mãe em um sítio em Araçatuba antes de residir no local dos fatos. Sua mãe teve a ideia de alugar a casa no Bairro Engenheiro Taveira. Morava com sua mãe e Wellington na residência. Seu padrasto não morava na casa. Conhecía Wellington desde a infância e o convidou para morar na casa. Trabalhavam juntos montando tenda em Araçatuba e Jales fazia três meses. Não conhecia os policiais. Nunca foi processado. A casa possui três quartos, sala, cozinha e banheiro. Sua mãe tinha saído da casa e estava morando somente com Wellington. Sua mãe residia no Bairro São José. Comentou para os policiais que comprou a droga para vender. É usuário, mas também vende às vezes.

Ocorre que a versão apresentada pelos réus não convence, vez que além de inverossímil e absolutamente contraditória ao que disseram na fase policial ---na ocasião, João alegou que adquiriu com Wellington a droga apreendida e que a fracionaram para venda a eventuais interessados, o que foi confirmado por Wellington, ambos alterando completamente tal versão em Juízo, como já visto, alegando Wellington, agora, que havia adquirido, para consumo, a maconha já fracionada em setenta e cinco porções (pelo irrisório valor de R\$80,00!!!), enquanto que João afirmou não ter conhecimento sobre o entorpecente apreendido no quarto de Wellington, bem como sobre se o corréu também vendia droga---, restou isolada no contexto probatório, que os compromete.

De fato, o policial militar Marcelo Alberto dos Santos, ouvido em Juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo Bairro Engenheiro Taveira quando adentraram na Rua Minas Gerais e avistaram dois indivíduos caminhando na direção da equipe policial. Ao perceberem a presença da viatura, os dois disfarçaram e cada um seguiu para um lado rapidamente, o que chamou a atenção. Resolveram abordar os indivíduos e o cabo Santos realizou busca pessoal em ambos. Foi encontrada a quantia de R\$ 80,00 em dinheiro no bolso da bermuda de João e R\$ 219,00 com Wellington. Indagados, os acusados lhes disseram que residiam naquela via. Como os réus exalavam odor característico de quem fumou maconha, perguntaram a eles se eram usuários, o que João confirmou dizendo que possuía um pedaço de maconha na residência dele. Inicialmente, Wellington negou ser usuário e afirmou que o dinheiro encontrado com ele era fruto de "bicos" que fazia. João lhes disse que não trabalhava e não soube explicar a origem do dinheiro localizado com ele. Quando Wellington percebeu que a equipe policial iria até a casa dele, acabou confessando que era usuário e que também guardava maconha para consumo próprio. Dirigiram-se à casa dos acusados,

situada na mesma via, numeral 159, onde foram recebidos pelo sogro de João, Moacir, que estava na porta da residência e franqueou a entrada dos policiais, acompanhando a diligência. Confirmou que os réus também autorizaram a entrada. Os acusados estavam do lado de fora com outros policiais e somente Moacir acompanhou as buscas. Entraram no quarto de Wellington e, de imediato, encontraram, em cima da cama, um saco plástico contendo setenta e cinco porções de maconha já preparadas para venda, além da quantia de R\$ 34,00 em moedas no guarda-roupa dele. Indagados novamente, ambos os réus confessaram a traficância e João lhes disse ainda que havia a quantia de R\$ 360,00 em dinheiro e um pedaço de maconha no quarto dele. Foram até o quarto de João acompanhados de Moacir e todos viram a droga e o dinheiro. Não conhecia os acusados. Os réus lhes disseram que residiam no Bairro São José anteriormente e que os dois resolveram alugar essa casa para a venda de droga no local. Os acusados estavam estruturados para o tráfico. João lhes falou que tinha dinheiro no quarto dele após a localização da droga no quarto de Wellington. Os réus não foram alvos de investigação prévia e o que motivou a abordagem foi o comportamento deles quando avistaram a viatura. Apareceram várias pessoas, dentre elas a namorada de Wellington, e uma senhora que chegou ao local disse que havia alugado essa casa para a mãe de um dos acusados. Os réus lhes disseram que não fazia muito tempo que moravam naquela casa. Não possuía informações de que aquele local era ponto de venda de droga.

No mesmo sentido, ouvido em Juízo, o policial militar José Roberto dos Santos disse que estavam em patrulhamento pelo Bairro Taveira quando viram os dois indivíduos, que se separaram e tentaram ir para direções opostas ao perceberem a presença da viatura. Decidiram abordar os indivíduos e não havia nada de ilícito com eles, apenas dinheiro. João tinha a quantia de R\$ 80,00, enquanto que Wellington possuía R\$ 219,00. Em entrevista, os acusados lhes disseram que residiam juntos nas proximidades e João ainda confessou que tinha um pouco de maconha na casa e que era usuário. Wellington, por sua vez, alegou que não era usuário e que não tinha nada de ilícito na residência. Durante o deslocamento até a casa deles, Wellington acabou confessando que também tinha um pouco de entorpecente no local. Quando chegaram, o padrasto estava em frente ao imóvel e lhes franqueou a entrada, pelo que iniciaram as buscas na residência. Adentrou na casa acompanhado do padrasto e localizou, no quarto de Wellington, em cima da cama, uma sacola plástica contendo várias porções de maconha já embaladas e prontas para venda, além de dinheiro. No quarto de João, localizaram mais uma porção grande de maconha. Posteriormente, os acusados confessaram que estavam vendendo entorpecente. Também foi encontrado dinheiro no quarto de João. Localizou setenta e cinco porções de maconha no quarto de Wellington. Encontraram dinheiro no quarto dos dois, mas não se recorda a quantia exata que havia no quarto de cada um. Não fazia muito tempo que os réus moravam naquela residência. Somente os dois residiam na casa. Não conhecia os acusados. Não possuía informações de tráfico naquela casa.

E não há porque se colocar em dúvida a versão dos policiais, porque como qualquer outra testemunha eles prestam compromisso de dizer a verdade, e não viriam a Juízo apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizaram. Note-se que não há nos autos prova de qualquer desavença anterior entre os policiais ouvidos em Juízo e os réus --- sequer se conheciam---, de forma que seus depoimentos merecem credibilidade, pois não teriam qualquer motivo para acusar injustamente um inocente. Enfim, não se pode desconsiderar uma prova por mera presunção, sem prova de suspeita ou má-fé.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“Por sua vez, o art. 207 estabelece quais as pessoas proibidas de depor, o que se dá em razão de função, ministério, ofício ou profissão, não estabelecendo qualquer restrição aos agentes que efetuem a prisão em flagrante no sentido de servirem como testemunhas. Assim, desde que tais depoimentos não se tornem suspeitos ou indignos de fé, têm plena validade em face da lei (TJSP - AC- Rel. Hoepfner Dutra - RT

416/96).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/2756).

Assim, o conjunto probatório é farto na demonstração de que toda a droga apreendida realmente pertencia aos acusados e que se destina ao tráfico, como por eles admitido na fase policial.

Isso porque, a considerável quantidade de maconha apreendida e a forma como estava acondicionada ---uma porção maior e em setenta e cinco porções menores, já desfragmentadas e prontas para imediata comercialização---, além da apreensão de dinheiro em poder dos acusados sem comprovação de origem lícita (R\$ 693,80), ou seja, o produto do crime, demonstram de forma cabal a finalidade do tráfico de entorpecentes.

Verifica-se, portanto, que a prova acusatória forma um todo coeso e concorde, perfazendo a necessária certeza para a prolação do decreto condenatório em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, ante estarem demonstradas, in casu, de forma indubitável, a autoria e materialidade delitiva, afastando-se toda e qualquer tese absolutória.

Por outro lado, não há prova segura nos autos de que os réus teriam se associado para a prática do tráfico de entorpecentes. O que ficou evidenciado é que eles, momentaneamente, se reuniram para vender entorpecentes na residência e sustentar o vício que possuem, conduta que se subsume ao delito do artigo 33, "caput" da Lei de Drogas, não permitindo, somente pelo mero concurso de agentes, a condenação pelo artigo 35 da mesma Lei.

Com efeito, a despeito da prova dos autos demonstrar a participação conjunta dos acusados na conduta delituosa, a verdade é que as circunstâncias do fato versado no presente processo indicam mais um mero concurso de agentes havido entre eles do que uma verdadeira associação, que pressupõe, ainda que em grau mínimo, certa estabilidade e organização entre os agentes.

E, diante da ausência de comprovação da efetiva associação entre os agentes voltada à prática do crime de tráfico de entorpecentes, os acusados devem ser absolvidos em relação à imputação do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Destarte, de rigor a condenação dos réus apenas pelo crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Os réus não ostentam antecedentes criminais. Analisando, ainda, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, deixo de reconhecer as atenuantes de ser o réu Wellington menor de vinte e um anos (auto de qualificação de fls. 13) e da confissão em relação ao réu João, vez que a pena base já foi fixada no patamar mínimo legal e no direito brasileiro “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula nº 231 do STJ).

Na terceira fase de dosimetria penal, entendo presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, vez que os acusados não ostentam antecedentes criminais e não há prova nos autos de que integrem organização criminosa ou que se dediquem às atividades criminosas. Considerando a quantidade de droga apreendida (embora grande o suficiente para caracterizar o tráfico diante das circunstâncias do fato, como já analisado, não é tão expressiva), bem como o fato de que os réus são jovens e não ostentam qualquer antecedente criminal, reduzo a pena base em 2/3, totalizando, assim, um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras de reprimenda, calculada a de multa no patamar mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar JOÃO NUBIATO DA SILVA ROCHA e WELLINGTON ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA, qualificados nos autos, ao cumprimento de um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a cento e sessenta e seis dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e absolvê-los da imputação do artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ressalto que este magistrado sempre teve o entendimento de que em relação ao tráfico de entorpecentes o regime inicial para o cumprimento de pena deve ser o fechado, único recomendável diante da latente e concreta gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas, restando inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que, ainda que alguns requisitos do artigo 44, do Código Penal fossem favoráveis ao réu, não estaria configurado o previsto no inciso III, in fine, do mencionado dispositivo legal, ou seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". O traficante é um grande responsável direto pela onda de violência que avassala o país, de forma que a insuficiência da substituição em tela para a repressão e prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes é patente, por conseguinte.

Ocorre que, em recente posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus coletivo nº 596.603/SP, determinou-se a fixação do regime aberto quando aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), resultando na pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Considerando a semelhança do caso em apreço, as reiteradas decisões dos Tribunais Superiores no mesmo sentido, bem assim, que o pleno do Supremo Tribunal Federal também declarou a inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" que consta no § 4º do artigo 33 da Lei de drogas (HC 97.256-RS), entendo presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal e substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, a primeira na forma de prestação de serviços à comunidade, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas, oportunamente, pelo Juízo das Execuções Criminais, e a segunda na forma de prestação pecuniária, consistente no pagamento a instituição pública ou privada com destinação social ---também a ser especificada pelo Juízo das Execuções Criminais--- do valor correspondente a um salário mínimo federal em vigor na época do efetivo adimplemento por cada réu.

Pelos mesmos motivos já expostos, em caso de revogação do benefício fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada.

Os réus poderão recorrer em liberdade, vez que respondem ao processo nesta condição.

Ressalto que eventual detração penal (art. 387, § 2º do CPP) deve ser postulada, oportunamente, ao juízo das execuções criminais competente, o qual possui condições de aferir a presença dos requisitos legais, especialmente os de natureza subjetiva.

Neste sentido: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar. Nulidade das provas obtidas mediante atuação da guarda municipal. Prisão em flagrante. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas corretas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, nocividade e diversidade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido” (TJSP; ApelaçãoCriminal1500272-11.2021.8.26.0542; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador:8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

Por fim, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, declaro perdidos em favor da União o celular e os valores apreendidos em poder dos acusados, pois se tratam de instrumento para a prática do crime de tráfico e produto dele.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Araçatuba, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA